

**Nr. 171 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes. 14. Juni 1935.***R 43 I/1473, Bl. 130–149 Umdruck<sup>1</sup>**Beginn:**Beginn:*

Im Reichsjustizministerium wird zur Zeit eine völlige Neuordnung des Strafverfahrens vorbereitet. Eine amtliche Kommission hat den Entwurf der neuen Strafverfahrensordnung aufgestellt und in erster Lesung beraten. Es ist geplant, den Entwurf zusammen mit dem Entwurf des in Vorbereitung befindlichen neuen Strafgesetzbuches zu verabschieden. Bis dies möglich sein wird, wird bei dem Umfang und der Wichtigkeit des großen Reformwerks, das keine Überstürzung verträgt, noch einige Zeit vergehen. Dringliche Fragen bedürfen der Vorwegregelung im Wege der Novellengesetzgebung.

Den ersten Anlaß zu der vorliegenden Novelle zur StPO – der ersten seit dem Staatsumschwung, die in das Gefüge der Strafprozeßordnung durch grundsätzliche Änderungen eingreift – gab der gleichzeitig vorgelegte Gesetzentwurf zur Abänderung des Strafgesetzbuchs. Die in diesem vorzusehenden zwei grundsätzlichen Neuerungen – die Zulassung der sogenannten Analogie und der sogenannten Wahlfeststellung – verlangen notwendig auch ergänzende neue Verfahrensvorschriften, um ihnen vollen Erfolg zu sichern. Diesem Ziel dienen die ersten beiden Ziffern des ersten Artikels der Novelle. Darüber hinaus verfolgt die Novelle das Ziel, die Gedanken der freieren Stellung des Richters und der Durchsetzung der materiellen Gerechtigkeit, die der Einführung der Analogie und der Wahlfeststellung zugrunde liegen, auch in der sonstigen Gestaltung des Verfahrens mehr als bisher zur Geltung zu bringen und damit den Strafprozeß auf den Geist des neuen Staates umzustellen. Diesem Ziele dienen die Vorschläge über das freiere Ermessen des Gerichts bei Beweiserhebungen<sup>2</sup>, die Beseitigung von einseitigen Bindungen des Rechtsmittelgerichts (Beseitigung des Verbots der *reformatio in peius*)<sup>3</sup>, die Befreiung des Reichsgerichts von Bindungen an Urteile der Vergangenheit, wodurch dem Reichsgericht die Umstellung seiner Rechtsprechung auf dem Geist der neuen Zeit erleichtert werden soll<sup>4</sup>, die freiere Stellung der Staatsanwaltschaft<sup>5</sup> und endlich die von dem Gerechtigkeitsempfinden der gesunden Volksanschauung geforderte Ermöglichung der Aburteilung flüchtiger Verbrecher<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Mit GesEntw. auch überliefert in: R 43 II/1514, Bl. 219–247; R 22/206, Bl. 90–119; R 22/862, Bl. 370–398. Das Gesetz diene der verfahrensrechtlichen Umsetzung der gleichzeitig vorgelegten Strafrechtsnovelle; s. deshalb ergänzend Dok. Nrr. 116 und 170. Zu Inhalt und Bedeutung eingehend: GRUCHMANN, Justiz, S. 1060–1068.

<sup>2</sup> Möglichkeit der Ablehnung eines Beweisantrags durch das Gericht, „wenn es nach seinem freien Ermessen die Erhebung des Beweises zur Erforschung der Wahrheit nicht für erforderlich hält“ (§ 245 StPO).

<sup>3</sup> Möglichkeit der Abänderung des Urteils zum Nachteil des Angeklagten durch das Berufungsgericht (§ 331 StPO).

<sup>4</sup> Hierzu Art. 2 der Vorlage:

„Das Reichsgericht als höchster deutscher Gerichtshof ist berufen, darauf hinzuwirken, daß bei der Auslegung des Gesetzes dem durch die Staatserneuerung eingetretenen Wandel der Lebens- und Rechtsanschauung Rechnung getragen wird. Damit es diese Aufgabe ungehindert durch die Rücksichtnahme auf die aus einer anderen Lebens- und Rechtsanschauung erwachsene Rechtsprechung der Vergangenheit erfüllen kann, wird folgendes bestimmt:  
Bei der Entscheidung über eine Rechtsfrage kann das Reichsgericht von einer Entscheidung abweichen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.“

<sup>5</sup> Vgl. Art. 4 der Vorlage: Beseitigung der notwendigen Voruntersuchung und Einführung von Hilfsuntersuchungsrichtern; Ermessensfreiheit bei der Verfolgung der von Opfern einer Erpressung begangenen Straftat, um die Ergreifung der Erpresser zu erleichtern (letzteres von Hitler gefordert).

<sup>6</sup> Art. 6 der Vorlage: Neufassung der §§ 276–282 StPO; besonders befürwortet vom StdF.

Alle diese Vorschläge liegen in der Zielrichtung der im Gange befindlichen Gesamtreform und nehmen nur einige der für diese geplanten Neuerungen, die keinen weiteren Aufschub vertragen, voraus, sind also nur Wegbereiter der künftigen Gesamtreform und dienen zu ihrer Entlastung. Im einzelnen ist zur Begründung der vorgeschlagenen Vorschriften folgendes zu bemerken:

### Zu Art. 1

Zu Nr. 1. Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuchs bringt in seinem Artikel 1 eine grundlegende Neuerung<sup>7</sup>. Er läßt neben der im Strafrecht bisher allein zulässigen unmittelbaren Gesetzesanwendung die *Rechtsschöpfung durch entsprechende Anwendung von Strafvorschriften* zu. Diese neu eingeführte zweite Rechtserkenntnisquelle ist dem Strafgesetz im engeren Sinne völlig gleichwertig. Ob sie Platz greift, müssen die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte demnach genau so gut prüfen wie bei jeder ausdrücklichen Strafvorschrift. Aber die Neuerung bedeutet einen solchen Bruch mit überkommenen Anschauungen, daß es geboten erscheint, Gerichte und Staatsanwaltschaften auch in der Strafprozeßordnung ausdrücklich auf sie hinzuweisen.

Die Überschrift des Artikels<sup>8</sup> bringt zum Ausdruck, welche Tätigkeit der Richter ausübt, wenn er ein Strafgesetz entsprechend anwendet. Er erkennt eine Lücke, die das Gesetz selbst nicht hat schließen können, und er füllt sie aus<sup>9</sup>. Damit übt der Richter, indem er einen vom Gesetz ausdrücklich ausgesprochenen Rechtsgedanken anwendet und erweitert, eine Tätigkeit aus, die der des Gesetzgebers verwandt ist. Daß der Richter keinen Eingriff in die Rechte des Gesetzgebers vornehmen darf, indem er über den erklärten Willen des Gesetzes hinaus Taten bestraft, bedurfte keiner besonderen Hervorhebung. Aber der Richter kann irren. Er kann das Gesetz mißverstehen. Man hat deshalb vorgeschlagen, die entsprechende Gesetzesanwendung mit Vorsichtsmaßregeln zu umgeben, besondere und hohe Gerichte mit einer Überprüfung zu betrauen, die Rechtsmittel zugunsten des Angeklagten zu erweitern und zu verstärken. Der Entwurf folgt diesen Vorschlägen nicht. Er gibt aber der Staatsanwaltschaft als der Vertreterin der Staatsführung die Möglichkeit, ihren Standpunkt in dieser Frage stärker als sonst zur Geltung zu bringen. Wenn die Staatsanwaltschaft rügt, daß das Gericht zu Unrecht ein Strafgesetz entsprechend angewendet oder nicht angewendet habe, dann soll sie auch dann das Rechtsmittel der Revision haben, wenn sie selbst die Berufung eingelegt und deshalb nach den Bestimmungen der Notverordnung vom 14. Juni 1932<sup>10</sup> das Recht auf Revision verwirkt hat. So kann sie jeden Fall, bei dem die Notwendigkeit dafür besteht, an ein Revisionsgericht bringen. Dieses Recht erhält die Staatsanwaltschaft aber nicht wegen der einzelnen Sache, die abgeurteilt worden ist, sondern wegen der grundsätzlichen Bedeutung, die jedem Falle beizumessen ist, in dem der Richter eine das gesetzte Strafrecht erweiternde, rechtsschöpfende Tätigkeit vornimmt oder ablehnt. Dem Verurteilten selbst ein erweitertes Rechtsmittelrecht zu geben, besteht danach keine Veranlassung.

Bei der entsprechenden Anwendung von Strafvorschriften wird es sich oft um eine Fortentwicklung des Rechts handeln, deren Richtung für die Gemeinschaft von einschneidender Bedeutung ist. Deshalb ist weiter die Möglichkeit vorgesehen, solche Revisionssachen dem Reichsgericht zur Entscheidung vorzulegen, auch wenn nach den allgemeinen Vorschriften das Oberlandesgericht zuständig wäre<sup>11</sup>. Die Zuständigkeit des Reichsgerichts wird hier durch den einfachen Antrag der

<sup>7</sup> S. Dok. Nr. 170, insbes. Anm. 8: neuer § 2 StGB.

<sup>8</sup> Artikel 1. *Freiere Stellung des Richters. 1. Rechtsschöpfung durch entsprechende Anwendung der Strafgesetze.*

<sup>9</sup> Die entsprechende Befugnis wurde durch Art. 1 Ziff. 1a der Novelle als neuer § 267a StPO formuliert: „Ergibt die Hauptverhandlung, daß der Angeklagte eine Tat begangen hat, die nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient, die aber im Gesetz nicht für strafbar erklärt ist, so hat das Gericht zu prüfen, ob auf die Tat der Grundgedanke eines Strafgesetzes zutrifft und ob durch entsprechende Anwendung dieses Strafgesetzes der Gerechtigkeit zum Siege verholfen werden kann (§ 2 des Strafgesetzbuchs).“

<sup>10</sup> VO des RPräs. über Maßnahmen auf dem Gebiete der Rechtspflege und Verwaltung (RGBL. I S. 285), T. I Kap. 1.

<sup>11</sup> Durch die Novelle eingeführter neuer § 347a StPO:

Staatsanwaltschaft begründet. Dieses Recht wird der Staatsanwaltschaft auch dann gegeben, wenn nicht sie, sondern der Verurteilte die Revision eingelegt hat. Die Staatsanwaltschaft muß einen solchen Antrag spätestens vor Beginn der Hauptverhandlung des Revisionsgerichts stellen.

Der Entwurf sieht vor, daß der Antrag zurückgenommen werden kann. Dabei ist an den Fall gedacht, in dem der Oberreichsanwalt – im Gegensatz zur örtlichen Staatsanwaltschaft – zwar nicht die Durchführung der Revision, wohl aber die Anrufung des Reichsgerichts für unnötig hält.

Im übrigen erschien es nicht erforderlich, die Strafprozeßordnung, das Gerichtsverfassungsgesetz oder die Strafregisterverordnung mit Rücksicht auf die Neuerung zu ergänzen. Die Strafbarkeit der Tat wird begründet durch § 2 des Strafgesetzbuchs. Die Zuständigkeit regelt sich also nach den Vorschriften, die für das entsprechend anzuwendende Gesetz bestehen. Nur dieses Gesetz ist (zusammen mit § 2 des Strafgesetzbuchs) in der Anklageschrift, im Eröffnungsbeschluß, in der Urteilsformel und im Strafregister anzuführen. Die Einschränkungen, die das Legalitätsprinzip erfahren hat, gelten selbstverständlich auch für den Bereich der neuen Vorschrift.

Zu Nr. 2. Die zweite Neuerung des Entwurfs zur Änderung des StGB, die eine Ergänzung der StPO erforderlich macht, ist die Zulassung der *Wahlfeststellung*<sup>12</sup>.

Welche Voraussetzungen für die Wahlfeststellung bestehen und aus welchem Gesetz die Bestrafung zu erfolgen hat, ist im materiellen Recht bestimmt.

Erweist sich eine eindeutige Feststellung als unmöglich, kommt aber das Gericht zu dem Ergebnis, daß der Angeklagte aufgrund einer Wahlfeststellung zu verurteilen ist, so hat es den Angeklagten in der Urteilsformel nur der Verletzung des mildesten der in Betracht kommenden Strafgesetze schuldig zu sprechen. Es soll also nicht eine Verurteilung in der Art erfolgen dürfen, daß der Angeklagte entweder der Kindesaussetzung oder fahrlässigen Tötung schuldig sei, sondern der Angeklagte ist nur wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen.

Diese Art des Urteilsspruches trägt den Bedenken Rechnung, die gegen die Zulässigkeit der Wahlfeststellung und der wahlweisen Verurteilung erhoben worden sind. Ein solcher Spruch ist in sich genügend fest und wird auch durch die Darlegung der Urteilsgründe, daß der Angeklagte möglicherweise die Tat in anderer Art begangen hat, in seiner Stärke nicht beeinträchtigt. Man kann einem solchen Urteil auch nicht vorwerfen, daß es in sich unehrlich sei. Das Gesetz selbst ermächtigt den Richter, unter den dargelegten Voraussetzungen aus dem milderen Gesetz zu verurteilen. Unehrlich wäre nur ein Verfahren, das den Richter zwingt, eindeutige Feststellungen zu treffen, wo er sie nicht mit gutem Gewissen treffen kann, aber doch treffen muß, wenn er einen zweifellos Schuldigen der verdienten Strafe zuführen will.

Es entspräche nicht dem Sinne des Gesetzes, wenn von der Wahlfeststellung ein übertriebener Gebrauch gemacht würde. Niemals darf die neue Vorschrift dazu führen, daß auf Grund unklarer und verschwommener Erwägungen Verdachtsstrafen verhängt werden. Ziel jedes Strafverfahrens ist und bleibt die eindeutige Aufklärung des Sachverhalts. Daran ändert dieses Gesetz nichts. Nur da, wo ausnahmsweise trotz Anwendung aller zur Verfügung stehenden angemessenen Mittel eine eindeutige Aufklärung nicht möglich ist, nur da ist die Wahlfeststellung zulässig.

---

„Über die Revision entscheidet auf Antrag der Staatsanwaltschaft statt des Oberlandesgerichts das Reichsgericht, wenn die Staatsanwaltschaft geltend macht, daß in dem angefochtenen Urteil die entsprechende Anwendung eines Strafgesetzes (§ 2 des Strafgesetzbuchs) zu Unrecht erfolgt oder nicht erfolgt sei. Die Staatsanwaltschaft kann diesen Antrag auch dann stellen, wenn sie nicht selbst Revision eingelegt hat.

Der Antrag muß vor Beginn der Hauptverhandlung des Revisionsgerichts gestellt werden; er kann zurückgenommen werden, so lange die Hauptverhandlung vor dem Reichsgericht nicht begonnen hat.“

<sup>12</sup> S. Dok. Nr. 170, insbes. Anm. 13: neuer § 2b StGB. Darauf fußend fügte die Strafprozeßnovelle folgenden neuen § 267b in die StPO ein:

„Trifft das Gericht eine Wahlfeststellung (§ 2b des Strafgesetzbuchs), so ist der Angeklagte in der [Urteils-]Formel nur der Verletzung des anzuwendenden Strafgesetzes schuldig zu sprechen.

Die Urteilsgründe müssen angeben, welche Gesetze als verletzt in Betracht kommen. Die Tatsachen, die den Verstoß ergeben, sind festzustellen; es ist darzutun, weshalb eine eindeutige Feststellung nicht möglich ist.

Sieht das Gericht entgegen einem in der Hauptverhandlung gestellten Anträge von einer Wahlfeststellung ab, so müssen die Gründe dafür dargelegt werden.“

Deshalb verlangt das Gesetz, daß die Urteilsgründe darlegen müssen, warum die eindeutige Feststellung des Sachverhalts nicht möglich ist.

[...] <sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zur Verabschiedung des Entwurfs s. Dok. Nr. 178 P. 7b.

## **Zitierhinweis**

Nr. 171 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Gerichtsverfassungsgesetzes. 14. Juni 1935. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).  
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d171>